

刑法
No257

共通問題 R7-3

(配点: 2)

月 日

月 日

学生A、B及びCは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑪までの()内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑪までの()内には、それぞれ異なるものが入る。

【事例】

甲は、威力を用いて県議会委員会の条例案採決の事務を妨害した。

【会話】

学生A. 甲に(①)が成立するかについては、(②)が(①)の客体である(③)に含まれるかが問題となりますね。

学生B. 私は、(③)に(④)との立場から、甲に(①)が(⑤)と考えます。

学生C. (⑥)についてまで(①)の保護対象に含める必要はあるのですか。

学生A. 私は、(③)に(⑦)との立場から、甲に(①)が(⑧)と考えます。

学生C. Aさんの立場では、威力を用いて私立高校の入学試験を妨害した場合には(①)が(⑤)のに、公立高校で同じことをしても(①)も(⑨)も(⑧)ことになりかねず、不均衡ではありませんか。私は、(⑥)は(③)に含まれず、それ以外の(②)は(③)に含まれると考えます。【事例】における事務は、(⑥)に当たらず、(③)に含まれるので、甲に(①)が(⑤)と考えます。

学生B. Cさんの立場では、(⑩)場合、どのように考えるのですか。

学生C. その行為さえなければ遂行されたはずの本来の警察官の(②)が妨害された場合、その妨害された(②)の中に(⑥)が含まれていたとしても、強制力を行使し得る段階に(⑪)ので、その全体について(①)が成立すると考えます。

【語句群】

- a. 業務妨害罪 b. 公務執行妨害罪 c. 業務 d. 公務
e. 全ての公務が含まれる f. 全ての公務が含まれない
g. 成立する h. 成立しない
i. 強制力を行使する権力的公務 j. 非権力的公務
k. 職務質問中の警察官に対して威力を用いて抵抗した
l. 警察官に対して犯罪予告の虚偽通報がなされた m. ある n. ない

- ①a ③c ⑥i ⑧h ⑩l
- ①b ④e ⑥j ⑨a ⑩k
- ②c ④f ⑦e ⑨a ⑪m
- ②d ⑤g ⑦f ⑨b ⑪m
- ③d ⑤h ⑧g ⑩k ⑪n

() には順に、「① = a、② = d、③ = c、④ = e、⑤ = g、⑥ = i、⑦ = f、⑧ = h、⑨ = b、⑩ = l、⑪ = n」と入り、したがって、正解は肢1となる。

業務妨害罪の「業務」に公務が含まれるかについては、主に4つの学説がある。

1. 無限定積極説：公務は全て「業務」に含まれるとする。
2. 消極説：公務は全て「業務」に含まれないとする。
3. 限定積極説：権力性など一定の基準によって公務を区別して、公務の中には「業務」に当たるものと当たらないものがあるとし、「業務」に当たるとした一定の公務には業務妨害罪の成立を認めた上で、さらに、手段が暴行・脅迫であれば公務執行妨害罪の成立も併せて認める。
4. 公務振分け説：現業性、民間類似性、非権力性等によって公務を区別し、一定の公務には業務妨害罪の成立を認めるが、業務妨害罪が成立する公務は、たとえ手段が暴行・脅迫であっても公務執行妨害罪の成立を認めないとする。

公務振分け説における公務の区別の基準は3. 限定積極説とほぼ同じである。

①、②、③について

設問の事例、学生Aの第一発言、選択肢を見て、この問題は、業務妨害罪において公務が「業務」に含まれるかという有名な論点に関するものであると気づく。よって、①には「a. 業務妨害罪」が入り、②には「d. 公務」が入り、③には「c. 業務」が入る。

④、⑤、⑥について

学生Bの第一発言のみでは、選択肢を絞りきれない。そこで、直後の学生Cの第一発言を見ると、「業務」の保護対象の広範さに対する批判がされていること、また、学生Cの第二発言の二文目を見ると、ある公務は「業務」に含まれず、それ以外の公務は「業務」に含まれると説明しているため、学生Cはおそらく3. 限定積極説の立場に立っていると思われることに着目すると、学生Bは、

1. 無限定積極説の立場に立っていることがわかる。この立場から設問の事例を検討すると、甲は、「威力を用いて」県議会委員会の条例案採決の事務という公務（「業務」）を「妨害」しているのであるから、甲の行為に業務妨害罪が成立する。そして、1. 無限定積極説には3. 限定積極説から強制力を行使する権力的公務まで「業務」に含めるべきではないのではないかという批判が考えられる。よって、④には「e. 全ての公務が含まれる」が入り、⑤には「g. 成立する」が入り、⑥には「i. 強制力を行使する権力的公務」が入る。

⑦、⑧について

学生Bは1. 無限定積極説の立場に立っており、学生Cは、3. 限定積極説の立場に立っているといえる。そうすると、学生Aは2. 消極説の立場に立っているといえる。学生Aの立場から設問の事例を検討すると、甲は、「威力を用いて」県議会委員会の条例案採決の事務という公務を「妨害」しているものの、この公務は「業務」に含まれないのであるから、甲の行為に業務妨害罪は成立しない。よって、⑦には「f. 全ての公務が含まれない」が入り、⑧には「h. 成立しない」が入る。

⑨について

学生Aの2. 消極説の立場に対しては、威力を用いて私立高校の入学試験を妨害した場合には業務妨害罪が成立するのに、公立高校で同様のことをしても業務妨害罪も公務執行妨害罪も成立しない。

いことになりかねず、不均衡であるという批判がある（公務執行妨害罪は、手段が「暴行又は脅迫」であり、威力は「暴行又は脅迫」よりも広い概念なので、威力を用いて公務を妨害しても公務執行妨害罪が成立するとは限らない[○]）。よって、⑨には「b. 公務執行妨害罪」が入る。

⑩、⑪について

学生Bの第二発言のみでは、⑩の選択肢を絞りきれない。そこで、直後の学生Cの第三発言を見ると、「その行為さえなければ遂行されたはずの本来の警察官の（②＝d. 公務）が妨害された場合、その妨害された（②＝d. 公務）の中に（⑥＝i. 強制力を行使する権力的公務）が含まれていたとしても、強制力を行使し得る段階に（⑪）ので、その全体について（①＝a. 業務妨害罪）が成立する」となっていることから、強制力を行使する権力的公務が「業務」に含まれているかにかかわらず、業務妨害罪が成立するという流れになる選択肢を選ぶことになる。そもそも、3. 限定積極説を採ったとしても、強制力を行使する権力的公務が否かという基準は威力を念頭に置いたものであり、偽計によって妨害する場合には、全ての公務は「業務」に含まれるという立場（修正積極説）を採り得る。なぜなら、偽計による場合は自力排除力が妨害を排除する機能を持たないからである。そうすると、職務質問中の警察官に対して威力を用いて抵抗した場合は、警察官は自力排除力によって妨害を排除できるので、3. 限定積極説から強制力を行使する権力的公務が「業務」に含まれるかによって業務妨害罪の成立が左右される。他方、修正積極説からすると、偽計による業務妨害の場合は、全ての公務が「業務」に含まれるのであるから、強制力を行使する権力的公務が「業務」に含まれているかどうかという議論にかかわらず、業務妨害罪が成立する。よって、⑩には「1. 警察官に対して犯罪予告の虚偽通報がなされた」が入り、⑪には「n. ない」が入る。